

1500507-56.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... que estava no local trabalhando para o tráfico apenas como olheiro/campana, negando a propriedade e a posse da droga. Disse que é usuário de crack e tem antecedentes criminais de tráfico de drogas e roubo, que mora na rua, cata papelão e não tem filhos.

Em juízo o acusado disse que estava na entrada da viela, caiu no crack, morava na rua, catava papelão, tinha dinheiro no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-56.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000391

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067400/2022 - 03º D.P.

DIADEMA, 2067400 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Mauricio Navarro Juvino

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

MAURICIO NAVARRO JUVINO, qualificado às fls. 08/10, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 10 de março de 2022, por volta das 15h15, na Travessa Montes Claros, altura do nº 35, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 23 embalagens contendo 12,84g da droga cocaína, 10 embalagens contendo 1,71g da mesma droga, na forma de crack, e 18 embalagens contendo 27,30g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 14/17, agindo sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.54/57), o réu foi notificado e citado (fls.97/98), e apresentou defesa preliminar as fls.102/104, através do Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi

recebida em 10/05/2022 (fl.106).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, além dos maus antecedentes do réu, plurirreincidente, inclsuive, e a agravar sua pena, discordando por isso da redução dele e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem direito de apelo em liberdade, e mais a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a figura do art. 37 da Lei Antidrogas, ou que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 11/12, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 14/17 e 88/90), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais (fls.06/07), foram acionados via COPOM para atender uma denúncia anônima de um indivíduo que estaria traficando drogas e seria procurado pela justiça. Pelas informações passadas, o indivíduo seria magro, alto, pardo, estava de boné preto, camiseta preta, bermuda azul e cinza e chinelo azul e teria uma tatuagem em formato de bola (yin yang). Ao chegar ao local, encontraram o indivíduo com as características passadas. Visualizaram ele largar uma bolsa pequena que trazia em mãos e tentar correr ao avistar as viaturas, sendo abordado em seguida. Dentro da bolsa largada pelo indivíduo encontraram diversas porções de substâncias similares a drogas, individualmente embaladas. Dentro desta também havia certa quantidade de dinheiro em moedas. Questionado, o indivíduo disse que é usuário e trabalha apenas como olheiro para o tráfico. Em consulta, não foram encontradas informações a respeito do indivíduo ser procurado, conforme informava a denúncia anônima repassada.

Sob o crivo do contraditório o policial Thiago da Silva Ré respondeu que tinham características físicas, tatuagem, vestes (boné preto, bermuda da Ciclone, e camiseta preta), vulgo Fantasma, onde ele estaria vendendo drogas, que inclusive já é um ponto de venda de drogas conhecido, e o denunciante também disse que o suspeito seria procurado e que traficava no local indicado. Ele estava abaixado mexendo numa pochete. Assim que ele os viu, correu. Dentro da sacola estavam as droga e ele confessou que estava trabalhando para o tráfico e que seria olheiro. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu. Também apreenderam na pochete umas moedas, quase vinte reais. A denuncia dava as características do réu, e que ele seria o traficante,

Igualmente o policial Gustavo Teixeira reiterou que houve um denunciante que ligou 190 informando vestes, tatuagem e o vulgo dele, Fantasma, quem estaria inclusive procurado, e que estaria traficando. Só o réu estava no local e correu ao vê-los, deixando uma pochete que continha as drogas. Reconhece o réu e batiam com as informações dadas (bermuda da Ciclone, chinelo e camiseta). O réu disse ser usuário de crack e negou estar traficando, que seria só olheiro, mas só tinha ele ali, e se trata de uma biqueira que geralmente os olheiros usam rojão para avisar a chegada dos policiais, para avisar os traficantes e estes se evadirem. Já tinha visto o réu lá antes, mas não com drogas, e sim soltando rojão.

O réu, em solo policial (fl.08), negou que a droga apreendida fosse sua, bem como a pochete. Afirmou que estava no local trabalhando para o tráfico apenas como olheiro/campana, negando a propriedade e a posse da droga. Disse que é usuário de crack e tem antecedentes criminais de tráfico de drogas e roubo, que mora na rua, cata papelão e não tem filhos.

Em juízo o acusado disse que estava na entrada da viela, caiu no crack, morava na rua, catava papelão, tinha dinheiro no bolso para comprar algo para comer. Não estava com nenhuma bolsa, que estava longe de si. Não tem nenhum vulgo.

Apresentaram a bolsa e o levaram para o DP. Não mora ali perto, só ia vender as coisas e ir embora. Nega também ter dito que estaria trabalhando como campana. Os policiais olharam sua passagem e disseram que ele ia voltar para o Sistema.

Conhecia o policial Gustavo, porque estudaram juntos e nada tem contra eles. Estava com uma camiseta preta, chinelo, e uma bolsa com suas coisas, porque estava morando na rua.

Logo, os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu trouxe versão diversa da alegada em solo policial, quando se disse mero olheiro do tráfico, e nessa audiência ele negou ter dito isso, negando que trabalhasse de qualquer modo para o tráfico, e que estaria no local apenas para vender as coisas que catou na rua para poder usar o dinheiro para comer, e que os policiais teriam localizado a pochete com as drogas e disseram que ele ia responder, que voltaria para o Sistema, mas não fez prova disso, até porque afirmou não ter nada contra os policiais, que diga-se, não imputariam a ele um crime, apenas para prejudica-lo aleatoriamente.

Até porque, como já visto, os relatos dos policiais são uníssonos e coesos, harmônicos entre si. Ademais, houve uma denúncia anônima dando conta do indivíduo que estaria traficando, sendo fornecidas as características físicas, de vestes, tatuagem, e que bateram com as do réu. Não bastasse isso, ele estava sozinho, parado, mexendo na pochete onde depois localizaram as drogas, de modo que não procede sua negativa de autoria, nem sua anterior versão de ser mero olheiro, o que não provou, nem há prova de que o acusado tenha efetuado ato de mero auxílio, como avisar a chegada de policiais, por exemplo, dado que nem teria a quem avisar, por estar sozinho na biqueira. Por isso, fica desde já afastado pedido de desclassificação para a figura do art. 37 da Lei Antidrogas. Quanto mais tendo o réu negado nessa audiência trabalhar como olheiro do tráfico, negando ter dito isso aos policiais ou em sua oitiva policial, de modo que nem confissão nesse sentido há a embasar pedido subsidiário da Defesa.

Anoto que embora tenhamos apenas os relatos dos policiais, tem-se o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

E como visto, os policiais sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, e quem tinha as características físicas e de vestes conforme passadas na denúncia anônima como sendo o traficante, era quem estava na biqueira, sozinho, com a pochete contendo as drogas e o dinheiro proveniente da venda delas, e foi quem correu ao notar suas presenças, não havendo mais ninguém no local que pudesse vir a ser o vapor para que ele fosse apenas o olheiro, como tenta fazer crer e não prova.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Assim, ainda que o réu trabalhasse como olheiro, como alegado inicialmente, o fato é que foi preso em flagrante delito por estar guardando e trazendo consigo as drogas, ainda que momentaneamente, e, como dito, o suficiente a embasar a condenação por tráfico e não pelo crime do art. 37 da Lei Especial.

Ausente ainda qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade pelo fato do réu se dizer, e não provar, estar em situação de rua, tendo que vender papelão para sobreviver. Ressalto que tal argumento, de precariedade financeira, ou mesmo de ser usuário de droga, não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares, e nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. E a situação de usuário de drogas coexiste com o de venda delas, até para o sustento do vício, de modo que não se tratam de condutas que se opõe nem se excluem.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (51 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (51 no total) o que não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, mas considerando os maus antecedentes criminais do réu como comprovado a fl. 31/32 (condenação por tráfico na 3ª Vara Criminal local), e considerando que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, pois "Proibir a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da pena", consoante atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Na segunda fase, ausentes atenuantes em favor do réu. Presente a agravante da multirreincidência comprovada as fl. 29/31 (condenações por roubo), donde agravo a pena em 1/5, perfazendo 07 anos de reclusão mais 699 dias-multa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio

previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, específico, a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a plurirreincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado. Ademais, temos a Súmula n. 269 STJ - Regime semiaberto ao réu reincidente é cabível para pena até 4 anos e se as condições 59 forem favoráveis. Nada disso foi preenchido pelo condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário). Veja: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em que pese a

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime

inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra MAURICIO NAVARRO JUVINO, qualificado às fls. 08/10, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 699 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de bens e numerário apreendidos (fl.11), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa,

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA